

통상임금에 관한 판례의 변화와 통상임금의 과제

유 혜 경*

<국문초록>

통상임금이란 근로자에게 정기적 일률적으로 소정(所定)근로 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급금액, 일급금액, 주급금액, 월급금액 또는 도급금액을 말한다.(근로기준법 시행령 제6조 제1항) 통상임금은 특별하지 않은 날, 항상있는 일로서 통상의 근로에 대한 대가이다. 통상임금은 소정의 근로시간에 대한 소정의 정해진 업무를 한 것에 대한 대가이다. 따라서 소정근로시간 내의 업무라도 사전에 정해진 업무가 아닌 특별한 예외적인 업무에 대한 대가는 통상임금이 아니며 소정근로시간의 소정업무에 대한 근로의 대가가 아닌 특별한 대가는 통상임금이 아니다.

통상임금의 해당성에 관한 판례는 상여금의 통상임금의 해당성을 근무일수를 근거로 일할 계산하는 것으로부터 근무성적에 좌우되는 임금으로 보아 통상임금의 해당성을 부정한 판례(대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501판결)로부터 상여금이 퇴직자에 대하여 월별로 계산 지급한다는 것으로부터 기본급과 동일하게 판단하여, 근무성적에 따라 좌우되는 임금이 아니라고 보아 통상임금으로 인정한 판례(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91406판결: 금아리무진 사건)로 변화했다. 그리고 2013전원합의체 판결에서는 통상임금의 개념적 징표로 정기성, 일률성, 고정성을 구체화했고(대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결) 2024년 전원합의체 판결에서는 고정성의 요건을 폐기하여 통상임금의 범위를 확대하였다.(대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결)

통상임금의 해당성 판단에서 임금의 법적성질과 연결되어 그 해당성 여부가 판단되어지는 것이 중요하고 그러할 때 임금에는 ‘보장적 부분’의 임금이 현실적으로 존재한다고 생각된다. 보장적 부분의 임금이 존재하는 근거는 다음과 같다. 근로기준법상 근로자의 생존을 배려하기 위해 일정한 사회법적 보호와 규제를 가하면서 퇴직금, 휴업수당, 유급휴일수당, 연차휴가수당 등을 보장하고 있는

논문투고일자: 2025. 8. 26. 심사일자: 2025. 12. 11. 게재확정일자: 2025. 12. 20.

* 경희대학교 법과대학 법학박사

것을 고려한다면 현실적으로 근로를 제공하지 않고 받는 임금의 존재를 일률적 전면적으로 부정할 수 없다. 그리고 임금이분설을 부정하고 현실적 노무제공과 직접 관계되지 않는 모든 임금을 부정하는 논리는 근로기준법의 사회법적 기능을 망각하는 것으로 귀착된다.

이렇게 임금은 교환적 부분의 임금과 보장적 부분의 임금으로 이분되며 통상임금은 임금이분설에 근거 하에 교환적 부분의 임금과 보장적 부분의 임금으로 이분된다고 생각된다. 첫째, 통상임금은 소정근로의 대상성에 기초한 교환적 임금으로 구성되고 둘째, 통상임금은 보장적 부분의 임금으로서 정기적 일률적으로 지급되는 임금으로 구성된다. 보장적 부분의 임금이 구체적 근로제공과 직접 관계되지 않고 근로자의 생활을 보장하기 위해 지급되더라도 보장적 임금이 정기성과 일률성을 갖추면 그 보장적 임금은 기본급과 같이 변화되어 통상임금에 해당한다.

주제어: 통상임금, 정기적 일률적 임금, 교환적 임금, 보장적 임금, 임금의 법적 성질

— 목 차 —

- I. 서론
- II. 통상임금의 개념
- III. 통상임금에 관한 판례의 변화
- IV. 통상임금의 개념에 관한 향후의 과제
- V. 결론

I. 서론

통상임금이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 금액 등을 말한다.(근로기준법 시행령 제6조 제1항)

통상임금의 해당성 판단에서 판례는 정기상여금의 통상임금 해당성을 부정하는 판례에서 정기상여금의 통상임금 해당성을 긍정한 판례로 변화

하였고 나아가 2013전원합의체 판결에서 통상임금의 개념적 징표를 정기성, 일률성, 고정성으로 구체화하였고 2024전원합의체 판결에서는 정기성, 일률성, 고정성의 요건 중 고정성의 요건을 폐기하여 통상임금의 범위를 확대하였다.

통상임금이 법정수당(연장수당, 야간수당, 휴일근로수당)의 산정을 위한 도구개념으로서의 임금이지만 본질적으로 임금의 법적 성질과 관련한 평가를 하는 것이 보다 중요하다고 판단된다. 현실적으로 보장적 부분의 임금이 존재한다는 것으로부터 임금이분설의 전제하에 첫째, 소정근로의 대상성으로서의 교환가치로서의 통상임금을 인정하고 둘째, 보장적 부분의 임금 중 정기적 일률적 임금을 통상임금으로 판단해야 한다고 생각된다.

이하에서는 통상임금의 개념, 통상임금에 관한 판례의 변화를 검토하고 통상임금의 개념에 관한 향후의 과제를 검토하고자 한다.

II. 통상임금의 개념

통상임금은 평균임금과 마찬가지로 현실의 임금의 종류에 통상임금이 있는 것이 아니라 통상임금은 당해 근로자의 노동력제공에 관한 사전적 평가로서 도구적 개념의 임금이다.¹⁾ 통상임금은 소정근로 혹은 총근로에 대하여 사용자가 사전적으로 지급하기로 된 임금이며 실제 근로제공을 한 후 사후적으로 지급되는 임금과 구별된다.²⁾ 보통 통상임금은 당해 근로자의 노동력에 대응한 기본급과 정기적 일률적으로 지급하기로 정하여진 제 수당을 합산한 것을 말한다.³⁾ 통상임금은 해고예고수당, 시간외, 야간, 휴일근로의 가산임금, 연차휴가수당의 산정기초가 되는 것으로서 각종 수당을 산정하기 위한 도구개념으로서 평균임금이 사후적인 특징이

1) 유혜경, 「노동법」, 기저출판, 2015, 438쪽.

2) 유혜경, 앞의 같은 곳.

3) 유혜경, 앞의 같은 곳.

있는 것에 비해 통상임금은 사전적인 특징을 갖는다.

1. 정기적 일률적으로 소정근로의 양 또는 질에 대하여 지급하기로 된 임금

판례는 일률적으로 지급되는 것이란 ‘전체, 모든 근로자’에게 지급되는 것뿐만 아니라 ‘일정한 조건에 달한 근로자’에게 지급되는 것도 포함되고 여기서 말하는 ‘일정한 조건’이란 고정적이고 평균적인 임금을 도출하려는 통상임금개념에 비추어 볼 때 ‘고정적인 조건’이어야 한다고 한다.⁴⁾

「이 사건 고열작업수당은 사업장의 실제의 변화된 온도에 따른 고열등급대로 동일한 공정내의 근로자들에게 동일한 수당을 지급해왔고 일시적으로 결원이 생겨 작업반장이 공정별로 다시 조정하지 않는 한 동일한 공정에 지속적으로 근로하게 하였으므로 고정적인 조건에서 근로한 것이라고 보아야 한다. 그렇다면 이 사건 고열작업수당은 고열작업수당이 지급되도록 정하여진 공정에서 근로하는 모든 근로자에게 일정한 금액이 정기적, 일률적으로 지급되는 것으로서 통상임금에 해당한다.

단, 지원조의 경우 50%이상을 고열작업장에서 근무하면 고열작업수당을 지급하지만 그 미만으로 근무하면 고열작업수당을 지급하지 않으므로 근로성적에 따라 지급하는 것으로서 통상임금에 해당하지 않는다.」⁵⁾

위의 판례와 같은 태도로서 「600m이하 지하작업에 대하여 특수직무수당을 지급하고 있다 하더라도 그 업무가 고정적인 것이 아니고 작업진행에 따라 임시적으로 근무한 것에 불과하다면 이는 일률적 급여로서의 통상임금에 포함되지 않는다.」라고 하였다.⁶⁾

한편 근로자에 대한 임금이 1개월 이상의 기간마다 지급되는 것일 경우 그것이 통상임금에 포함될 수 있는지가 문제되는데, 정기적 일률적 지급의 요건은 반드시 1임금지급기의 충족여부로 형식적으로 판단할 필요

4) 대법원 2009. 9. 9. 선고 2004다41217 판결.

5) 대법원 2009. 9. 9. 선고 2004다41217 판결.

6) 대법원 1993. 5. 27. 선고 92다20316 판결.

는 없으며 실질적으로 정기성과 일률성을 갖추면 통상임금으로 보아야 한다.

판례는 의료보험조합이 매년 1회이상 일정시기에 모든, 전체 근로자에게 지급하는 체력단련비나 월동보조비를 통상임금이라 보았다.⁷⁾

2. 소정근로의 대상성

통상임금은 사용자와 근로자가 근로하기로 정한 소정근로에 대하여 지급하기로 정한 임금이다. 따라서 당해 근로자의 노동력의 교환가치를 대상으로 한다. 소정근로의 대상에 해당되는지 여부와 관련하여 주로 문제되는 것은 복리후생비가 통상임금에 해당되는지이다. 판례는 「비록 명칭이 복리후생비라고 하여도 모든, 전체 근로자에게 일률적으로 지급되고 근로계약상 사용자에게 그 지급의무가 주어져 있다면 기본근로제공에 대한 교환적 가치를 가진 통상임금에 해당한다고 판단했다.」⁸⁾

판례의 다수는 식사비에 대해서 그 식비가 고정적 일률적으로 지급되었다면 원칙적으로 통상임금에 해당하는 것으로 판단하고 있다.⁹⁾

가족수당의 경우에는 근로의 양 및 질과 관계없는 부양가족이 있는 근로자에게만 지급되면 통상임금에 해당되지 않는다고 판단한다.¹⁰⁾ 그러나 가족수당이라는 명목으로 지급된다고 하더라도 가족이 없는 근로자에게도 일률적으로 부양가족이 있는 근로자가 지급받는 가족수당을 지급받는 경우라면 그 경우의 가족수당은 고정적, 일률적 수당으로서 통상임금에 해당한다.¹¹⁾

통상임금은 근로자가 제공하기로 정한 근로의 양과 질에 대한 교환가치적 성격을 근거로 한 임금이기에 각각의 수당의 형식적 명칭이 중요한

7) 대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501 판결.

8) 대법원 1990. 12. 26. 선고 90다카12493 판결.

9) 김유성, 「노동법 I」, 법문사, 2005, 88쪽.

10) 대법원 1990. 12. 29. 선고 90다카12493 판결.

11) 대법원 1992. 7. 14. 선고 91다5501 판결.

것이 아니라 사전적 교환가치로서의 임금의 실질을 가지는가가 본질적 문제이다.. 평균임금은 근로자가 지급받은 금액을 기준으로 결정되는 사후적인 성격을 가지지만 통상임금은 근로자가 소정근로시간에 통상적인 근로를 제공하면 지급받게 될 ‘예정된 임금’의 성격을 가지고 있고 이러한 통상임금의 본질적 기능을 고려하여 통상임금의 해당성이 판단되어야 한다.¹²⁾

통상임금을 문언 그대로 평가하면 ‘통상’의 임금이고 통상의 사전적 의미는 항상 있는 일로서 통상의 근로에 대한 대가이다.¹³⁾ 즉 통상임금은 소정의 근로시간에 소정의 정해진 근로를 이행한 것에 대한 대가이다. 따라서 소정근로시간 내의 업무라도 사전에 미리 정해진 업무가 아닌 특별한 하고도 예외적인 업무에 대한 대가는 통상임금이 아니며 소정 근로시간의 소정 근로에 대하여 지급되는 일반적인 대가가 아닌 특별한 대가는 통상임금에 해당하지 않는다.¹⁴⁾ 이렇게 통상임금의 개념에서 추출되는 통상성의 개념은 세 가지의 통상성을 징표함으로서 근로시간의 통상성, 업무의 통상성, 근로대가의 통상성에 따른 통상임금의 범위를 확정해 낼 수 있다.¹⁵⁾

3. 근무성적 내지 실적에 따라 지급되는 임금의 제외

통상임금은 통상임금 산정사유 발생당시 당해 사업장에서 근로를 제공하고 있는 근로자가 그가 제공하기로 한 근로의 양과 질에 대해 어떠한 평가를 받고 있느냐란 사전적 평가개념으로서 근로의 양과 질에 상응한 교환가치를 염두에 둔 개념이기 때문에 특별한 사정으로 근로자가 받는 급여액이 많거나 적게 되는 경우가 있어도 이에 영향을 받지 않는다.¹⁶⁾

12) 박수근, “통상임금의 실태와 본질에 관한 검토”, 『인권과 정의』 443, 2014, 149쪽.

13) 김성진, “통상성으로 본 대법원의 통상임금법리”, 한국노동법학회, 『노동법학』 제 49호, 2014, 41-42쪽.

14) 김성진, 앞의 논문, 42쪽.

15) 김성진, 앞의 논문, 42쪽.

즉 통상임금을 통하여 시간의 근로수당, 휴일근로수당, 야간근로수당, 연차휴가수당 등이 결정되므로 통상임금은 근로자가 제공하는 근로의 양과 질에 대한 사전적 평가로서 고정적, 일률적이어야 하고 그렇기 때문에 실제 근로제공의 실적에 따라 지급되는 임금 내지 수당은 통상임금의 범위에서 제외된다.

판례는 상여금의 지급여부가 근로자들의 현실의 근무성적에 따라 달라지는 경우 그것은 고정적인 임금이라 할 수 없으므로 통상임금에 속한다고 할 수 없다고 했다.¹⁷⁾ 또한 현실의 근무성적에 따라 달라지는 것으로서 그것이 고정적인 임금이라 할 수 없는 정근수당은 통상임금에 속하지 않는다고 했다.¹⁸⁾ 그리고 승무원이 국내선에 탑승하게 되는 경우에 한해서 지급되는(이륙과 착륙횟수에 따라 지급되는) 이륙, 착륙수당도 통상임금에 포함되지 않는다고 하였다.¹⁹⁾

「실제의 근무성적에 따라 지급여부가 달라지는 임금은 고정성을 결여하여 통상임금에 해당하지 않는다. 비행수당은 승무원의 경우 실제 비행시간이 30시간 이상인 조건을 충족한 경우 60시간의 비행수당을 지급하고 승무결근자 등으로서 공상기간이 월 중 10일 이상인 경우에는 비행수당이 지급되지 아니한 것에 비추어 보면 비행수당은 고정적 수당이 아닌 실제의 근무성적에 따라 지급여부가 달라지는 것이므로 통상임금에 해당하지 않는다. 또한 이륙, 착륙수당은 이륙, 착륙 횟수에 따라 지급되어 정기적, 일률적으로 지급되는 것이 아니기에 통상임금이 아니며, 승무원이 해외에서 머무는 기간동안 지급되는 식사비는 체류지역마다 그 지급비용이 달라져서 해외체류라는 특수한 근무조건에 따라 지급되는 실비변상적 금원으로 통상임금에 해당하지 않는다.」²⁰⁾

16) 이철수, “통상임금의 법리”, 서울대학교 노동법연구회, 「노동법연구」 제3호, 1993, 293-294쪽.

17) 대법원 1996. 2. 9. 선고 94다1950 판결.

18) 대법원 1996. 5. 10. 선고 95다2227 판결.

19) 대법원 1996. 6. 28. 선고 95다24074 판결.

20) 대법원 1996. 6. 28. 선고 95다24074 판결.

4. 통상임금에 따라 계산되는 제 법정수당의 제외

통상임금은 근로자가 제공하는 근로의 양과 질에 대한 사전적 평가로서 근로기준법상의 법정수당(시간외 근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당, 연차유급휴가수당, 해고예고수당)을 산출하기 위한 도구적 개념이다. 따라서 통상임금에는 당연히 통상임금으로부터 산출되는 근로기준법상의 제 법정수당이 포함되지 않는다.²¹⁾

「피고회사는 그 소속 근로자들과 1일 근로시간을 8시간으로 하는 근로계약을 체결하여 고용하여 왔으나 국내외의 건설공사를 시공하는 피고회사의 사업내용의 특수성에 따라 건설현장 근로자들은 연장근로와 휴일근로의 발생이 불가피하고 관리직근로자들의 경우 근무시간의 정확한 확인이 어려운 점 등을 감안하여 건설현장 근무 관리직근로자에게는 1일 3시간의 연장근로와 월 2회의 휴일근로를 기준으로 연장수당 및 휴일근로수당 그리고 건설현장 근무의 어려움을 감안한 지역수당(벽지수당)을 모두 합하여 <해외수당>이라는 명목으로 매월 일정액을 지급하여 왔는데, 피고가 해외수당이라는 명목으로 지급한 금원에는 실질적인 연장근로수당과 휴일근로수당이 포함되어 있는 이상 이에 해당하는 금원지급부분은 통상임금에 포함될 수 없다. 따라서 <해외수당>중 통상임금에 포함되는 것은 연장근로수당과 휴일근로수당을 제외한 나머진 지역수당(벽지수당)뿐이라 할 것이다.」²²⁾

21) 유혜경, 앞의 책, 440쪽.

22) 서울고법 1990. 3. 2. 선고 89나27081 판결.

Ⅲ. 통상임금에 관한 판례의 변화

1. 상여금의 통상임금 해당성을 부정한 판례(대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501 판결)

가. 내용

「피고 조합들의 지역의료보험조합 운영규정에 의하면 원심판시의 상여금은 예산의 범위 안에서 매년 4분기의 임금지급일에 각각 상여금 지급일에 기본급의 100%를 지급하는 것이나, 다만 입사 1개월 미만인 자 등에게는 지급되지 않고, 근속기간이 3개월 이상인 자로서 상여금 지급기간의 2분의 1 미만을 근무하고 퇴직한 자에 대하여는 근무일수를 근거로 일할 계산하여 지급하도록 규정되어 있다. 따라서 상여금의 지급여부는 결국 근로자들의 실제의 근무성적에 따라 달라지게 되어 그것이 고정적인 임금이라고 할 수 없으므로 통상임금에 속한다고 할 수 없다.」

나. 검토

상여금은 예산의 범위안에서 매년 4분기의 보수지급일에 각각 상여금 지급일 현재 기본급의 100%를 지급한다고 했으므로 ‘정기성’은 충족된다. 그런데 판례는 상여금지급대상에서 제외되는 자로서 근속기간이 3개월 이상인 자로서 상여금 지급기간의 2분의 1 미만을 근무하고 퇴직한 자에 대하여는 근무일수를 근거로 일할계산하여 지급하도록 규정하고 있어 그것은 결국 근로제공한 일수 만큼 상여금이 가산 지급된다는 것이고 결국 근무일수에 비례하여 상여금이 삭감되므로 따라서 상여금의 지급여부는 근무성적에 따라 달라지게 되어 고정적인 임금이라 할 수 없어 통상임금에 해당되지 않는다고 판단했다.

즉, 판례의 태도는 ‘근무일수를 근거로 일할계산’ → ‘근무성적에 따라 좌우되는 임금’ → ‘비고정적 임금’ → ‘통상임금 해당성 부정’으로 판단한 것이다. 상여금이 근로제공을 한 근무일 수만큼 일할 계산된다는 것은

결근하면 그만큼 비율에 의해 상여금이 삭감된다는 것이고 그렇기 때문에 근무성적에 따라 지급되는 임금이라는 것이다. 기본급의 경우 결근하면 그 만큼 기본급이 삭감되지만 그렇다고 기본급을 근무성적에 따른 임금이라 판단하지는 않는다. 각종 수당의 통상임금 해당성 판단에서 주로 문제되는 것은 해당 수당의 지급과 관련하여 근로일이나 근로시간에 대하여 감액규정을 두고 있는 경우 해당 수당이 고정성을 충족하지 않아 통상임금성이 부정되는가이다.²³⁾ 기본급에 대해서는 누구도 통상임금성을 부정하지 않지만 기본급도 근로제공을 하지 않는 경우 근로일수나 근로시간에 비례하여 감액된다.²⁴⁾ 그렇다면 근로일이나 근로시간에 대하여 감액규정을 두고 있는 경우라도 이는 임금공제의 문제일 뿐 근무성적과는 관계없는 문제이므로 해당 수당이 정기성과 일률성을 갖추었다면 통상임금에 해당한다고 판단해야 한다. 해당 판결은 ‘고정성’의 판단을 너무 엄격하게 하여 통상임금의 범위를 축소시켰다고 판단된다.

2. 상여금의 통상임금 해당성을 긍정한 판결(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91406판결: 금아리무진 사건)

가. 내용

「원심판결의 이유에 의하면, 원심은 그 채택증거를 종합하여, 이 사건 단체협약 제27조에서 상여금이 만근 기본급기준으로 6개월이상 근무시 350%, 3년이상 근무시 550%, 8년이상 근무시 650% 등으로 지급하되, 상여금지급은 분기별로 지급하며 매분기 말까지 재직한 자로 하고, 퇴직자에 대하여는 월별로 계산 지급한다고 규정하고 있고, 피고는 원고들에게 이 사건 단체협약에 따라 상여금을 분기별로 지급하였다는 사실을 인정 한 후, 이를 기초로 하여 상여금의 지급여부 및 지급액이 근로자의 실제 근무성적 등에 따라 좌우되는 것으로서 통상임금에 포함되지 않는다고

23) 유혜경, 앞의 책, 442쪽.

24) 유혜경, 앞의 책, 442쪽.

판단하였다. 단체협약 제27조에 따라 상여금은 매 분기말까지 재직한 자라고 규정하면서 추가적으로 덧붙여서 퇴직자에 대해서는 월별로 계산 지급한다고 규정하여 상여금지급에 관하여 중도에 퇴직한 자를 배제하는 것으로 볼 수 없다. 이는 상여금이 기본급과 마찬가지로 해석된다는 것으로 근로자가 상여금 지급 대상기간 중에 퇴직할 경우 퇴직 이후의 기간에 대하여는 상여금을 지급할 수 없지만 재직기간에 대해서는 재직기간에 상응하여 비례적으로 지급되는 것으로 해당 상여금은 그 지급여부가 근로자의 근무성적에 따라 지급되는 것이 아니라 그 지급금액이 확정된 것으로서 고정적인 임금인 통상임금에 해당한다.」

나. 검토

첫째, 이 사건 상여금은 6개월을 초과하여 계속 근로한 근로자에게 계속년수의 증가에 근거하여 비례적으로 산정한 금액을 분기별로 지급하는 것으로서 ‘정기성’을 충족한다.

둘째, 이 사건 단체협약 제27조에 ‘상여금 지급은 매 분기말까지 재직 한 자로 하고’라고 규정하면서도 끝이어 추가적으로 덧붙여 ‘퇴직자에 대해서는 월별로 계산 지급한다’고 규정함으로써 상여금 지급대상에서 중도에 퇴직한 근로자들을 배제한 것으로 볼 수 없기 때문에 ‘일률성’을 충족한다.

즉 ‘퇴직자에 대하여는 월별로 지급한다’는 의미는 기본급과 마찬가지로 해석되어 근로자가 상여금 지급대상 기간 중에 퇴직하면 퇴직 이후의 기간에 대하여는 상여금을 지급할 수 없지만 근로제공을 한 재직기간에 비례하여 재직일수에 비례하는 만큼은 상여금을 지급하겠다는 것으로 해석된다. 따라서 기본급과 같이 재직기간에 비례하여 상여금이 보장되므로 근무성적에 따라 지급되는 임금이 아닌 것으로서 정기적 일률적으로 지급되는 고정적인 임금으로 통상임금에 해당한다.

셋째, 이 판결에 대하여 동일한 조건에 대하여 기존의 대법원 판례²⁵⁾와

25) 대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501 판결.

다른 결론(재직기간에 비례하여 상여금을 지급하겠다고 하지만 한편에서는 해당 상여금을 근무성적에 따라 지급하는 임금으로 보았고 금아리무진 사건에서는 근무성적에 기초하지 않는 임금으로 판단했음)을 내리면서 종전의 판례와 달리 고정적 임금으로 판단한 이유를 밝히고 있지 않다고 비판하는 입장²⁶⁾이 있고 고정적 임금으로 보아 고정성의 요건을 완화했다고 하여 기존 판례보다 진일보한 해석론을 취하였다고 평가하는 입장²⁷⁾이 있다.

이 사건 상여금은 단체협약 제27조에 의하여 상여금지급은 매 분기말까지 재직한 자로 한다라고 규정하면서도 추가적으로 ‘퇴직자에 대하여는 월별로 계산 지급한다’고 규정하고 있다. 이는 상여금 지급대상에서 중도퇴직자를 배제한 것으로 볼 수 없는 것으로서, ‘기본급’과 동일하게 해석되어(기본급의 경우 근로제공을 안 한 경우 근로제공을 안 한 일수만큼 기본급이 삭감됨) 비록 근로자가 상여금지급 대상기간 중에 퇴직한 경우 퇴직 이후의 기간에 대하여는 상여금을 지급할 수 없지만 재직기간에 비례하여 상여금을 지급한다는 것으로서 고정적으로 확정된 금액이라는 것이다. 주목해서 보아야 할 것은 이 사건 상여금이 근로자의 근무성적 등에 좌우되는 것이 아닌 기본급과 동일하게 결근하면 기본급이 감액되는 것과 마찬가지로 퇴직시에도 재직기간에 비례하여 상여금을 받기 때문에 상여금 지급액이 확정된 고정적인 임금이라는 것이다.

본 판결은 ‘퇴직자에 대하여 월별로 계산 지급’한다는 규정을 기본급과 동일하게 판단함으로써 당해 상여금이 근무성적에 따라 좌우되는 임금인가의 판단에서 실질성을 확보하여 임금공제의 문제와 근무성적에 따른 임금인가의 문제를 구별하였다. 그런만큼 ‘고정성’의 요건을 완화하여 통상임금의 범위를 확대하였다고 평가할 수 있다.

26) 이승길, “상여금의 통상임금에 관한 판례법리의 소고”, 『가천법학』 제5권 제2호, 2012, 302쪽.

27) 김소영, “판례법리에 의한 통상임금 판단기준의 경향과 변화”, 한국비교노동법학회, 『노동법논총』 제25집, 2012, 294쪽.

3. 통상임금에 관한 전원합의체 판결(1)의 내용

가. 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결

(1) 통상임금에 관한 법리

「통상임금의 해당성 여부는 그 임금이 소정근로의 대가로 근로자에게 정기적, 일률적으로 지급되는 것인지를 통해 판단된다. 즉 통상임금여부는 임금의 명칭이나 지급기간의 장단 등에 따라 결정되는 것이 아니다. 소정근로의 대가란 근로자와 사용자가 소정근로시간에 일상적, 통상적으로 제공하기로 정한 근로자의 가치를 객관적으로 평가한 것을 말하고, 그 지급금품이 소정 근로시간을 근로제공한 후에 바로 직후나 가까운 기간 내에 지급되지 아니하였다고 하여 소정근로의 대가에서 제외되는 것은 아니다.」

(2) 통상임금의 개념적 징표로서 정기성, 일률성, 고정성의 의미 첫째, 정기성

「일정한 임금이 통상임금에 해당하기 위해서는 정기성의 요건을 갖추어야 한다. 정기성이란 반드시 1임금 산정기간을 충족하여야 하는 것이 아니라 근로의 대가가 1개월을 넘는 기간마다 분할 지급되는 경우에도 정기성은 충족된다. 따라서 정기상여금과 마찬가지로 1개월마다 지급되는 않지만 일정한 간격을 두고 주기적으로 지급되는 경우 정기성을 충족하여 통상임금에 해당한다. 즉 임금의 지급주기가 1개월을 넘는다는 이유로 통상임금에서 제외되는 것은 아니다.」

둘째, 일률성

「일정한 임금이 통상임금에 해당하기 위해서는 일률성의 요건을 충족하여야 한다. 일률성이란 요건은 모든 근로자에게 지급되는 것뿐만 아니라 일정한 조건 내지 기준에 달한 모든, 전체근로자에게 지급되는 것도 포함된다. 일정한 조건이 무엇인지가 문제되는데, 일정한 조건이란 고정

적이고 평균적인 임금을 산정하려는 통상임금의 개념에 비추어 볼 때 고정적인 조건이어야 한다. 일정한 조건이란 통상임금이 소정근로제공을 제공한 가치를 평가한 것임을 고려할 때 작업내용이나 기술 등 소정근로의 가치평가와 관련된 것이어야 한다. 따라서 부양가족이 있는 근로자에게만 지급되는 가족수당은 소정근로제공의 가치와 무관하므로 통상임금에 해당한다고 할 수 없고 반면에 모든 전체근로자에게 가족수당이란 명칭으로 지급하면서 실제 부양가족이 있는 근로자에게 일정액을 추가, 보충적으로 지급한 경우 전체근로자에게 지급된 기본금액은 소정근로의 가치이므로 통상임금에 해당한다.」

셋째, 고정성

「일정한 임금이 통상임금에 해당하기 위해서는 고정성의 요건을 충족하여야 한다. 고정성의 요소는 통상임금의 해당성 판단에서 주요한 기능을 하는데, 이 고정성의 요소는 통상임금을 다른 일반적인 임금이나 사후적인 성격을 가지는 평균임금과 구별해 줌으로서 사전적 확정성을 본질로 보여준다. 고정성이란 근로자가 제공한 근로에 대하여 그 업적이나 성과 기타의 추가적인 조건과 관계없이 당연히 확정되어 있는 성질을 말한다. 따라서 고정적 임금이란 소정 근로시간을 근로한 근로자가 그 다음날 퇴직하더라도 그 하루의 근로에 대한 대가로 당연히 지급받게 되는 최소한의 임금을 말한다. 해당 임금이 고정성을 갖추었다 함은 특정한 날에 소정근로를 제공하면 다른 추가적인 조건의 충족과 관계없이 당연히 지급되는 것을 말하는 것으로 ‘사전확정성’을 말한다. 추가적인 조건을 충족해야 지급되는 임금은 정기상여금과 같이 고정성의 요건을 충족할 수 없어 통상임금에 해당하지 않는다.」

(3) 이 사건에 대한 판단

「피고(갑을 오토텍유회사)는 상여금 지급규칙에 따라 상여금 지급대상 기간 중에 퇴직한 근로자에 대해서는 근무일수에 따라 일할 계산하여

지급한 사실을 알 수 있다. 이 사건 상여금은 근속기간에 따라 지급액이 달라지기는 하나 일정 근속기간에 이른 근로자에 대하여는 일정액의 상여금이 확정적으로 지급되는 것이므로 이 사건 상여금은 소정근로를 제공하기만 하면 그 지급이 확정된 것이라고 볼 수 있어 정기적 일률적으로 지급되는 고정적인 임금인 통상임금에 해당한다.」

나. 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결

「근로기준법이 법정수당 등의 산정기초 및 평균임금의 최저한으로 규정하고 있는 통상임금은 근로자가 소정근로시간에 일상적으로, 통상적으로 제공하는 근로인 소정근로제공의 대가로 지급하기로 약정한 금품이다. 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금도 그것이 정기적, 일률적, 고정적으로 지급되는 것이면 통상임금에 포함될 수 있다. 그리고 고정적인 임금이라 함은 임금의 명칭여하를 불문하고 일정한 날에 소정근로시간을 근로제공한 근로자가 그 다음날 퇴직한다 하더라도 그 하루의 근로제공에 대한 대가로 당연하고도 확실하게 지급받게 되는 최소한의 임금을 말하므로, 근로자가 일정한 날에 소정근로를 제공하면 추가적인 조건의 충족여부와 관계없이 당연히 지급될 것이 예정되어 지급여부가 사전에 확정된 임금은 고정성을 갖춘 것으로 볼 수 있다.근로자가 소정근로를 했는지 여부와는 관계없이 지급일 기타 특정시점에 재직중인 근로자에게만 지급하기로 정해져 있는 임금은 그 특정시점에 재직중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 요건이 된다. 그러한 임금은 이전에 근로를 제공했던 사람이라도 특정시점에 재직하지 않는 경우에는 해당 임금을 지급하지 아니하는 반면, 그 특정시점에 재직하는 경우에는 이전의 근로제공이 실현되지 않는 경우에도 해당 금품을 지급하는 것이 일반적이다. 그와 같은 조건으로 지급되는 임금이라면 그 임금은 이른바 ‘소정근로제공’에 대한 대가로서의 성질을 가질 수 없다.」

다. 검토

(1) 통상임금의 개념적 징표로서의 정기성, 일률성, 고정성

통상임금이란 소정근로의 대가로 근로자에게 지급되는 금품으로서 정기적, 일률적, 고정적으로 지급되는 것이다.

첫째, 정기성이란 임금이 일정한 간격을 두고 계속적, 지속적으로 지급되어야 함을 의미하고 그 지급주기가 1개월을 초과하더라도 일정한 간격을 두고 계속되기만 한다면 정기성을 충족하여 통상임금에 해당한다.

둘째, 일률성이란 모든 근로자에게 지급되는 경우 일률적이라 당연히 통상임금에 해당한다. 그러나 모든 근로자에게 지급되지 않는다고 하더라도 일정한 조건 내지 기준에 달한 근로자에게 지급되는 경우도 통상임금에 해당한다. 여기서 일정한 조건이란 고정적이고 평균적인 임금을 산출하려는 통상임금의 개념에 비추어 볼 때 고정적인 조건이어야 한다.

셋째, 고정성이라 함은 근로자가 제공한 근로에 대하여 그 업적, 성과 능력 등의 추가적인 조건과 관계없이 당연히 지급될 것이 확정되어 있는 성질을 말하고 일정한 날에 소정근로시간을 근로제공한 근로자가 그 다음날 퇴직한다 하더라도 그 하루의 근로제공에 대한 대가로 당연히 지급받게 되는 최소한의 임금이다.

2013 전원합의체 판결이 고정성과 관련하여 일정한 하루하루의 근로에 대한 대가로 당연히고도 확정적으로 지급받게 되는 최소한의 임금이라 판단하면서 당해 소정 근로제공에 대한 대상으로서의 ‘교환가치’를 통상임금으로 판단한 것은 옳다. 그런데 추가적인 조건의 충족여부에 따라 그 지급여부가 변동되는 임금은 고정성이 충족되지 않아 통상임금에서 제외된다는 판결의 내용은 통상임금의 본질과약에서 벗어나 있다. 추가적인 조건의 충족여부에 따라 그 지급여부가 변동된다는 것은 근로자가 근로제공을 한 후 조건의 미충족으로 임금을 받을 수 없다는 ‘임금의 사전포기’로서 임금미지급의 불법의 문제를 낳을 뿐이다.

예를 들어, 재직조건의 정기상여금의 경우에서 이전의 근로를 제공했던 경우에도 특정시점에 재직조건을 충족하지 않는 경우 정기상여금을

지급하지 않고, 그 특정시점에 재직하는 경우 이전에 근로를 제공하지 않은 경우에도 정기상여금을 지급하는 것은 고정성의 문제 여하가 문제되는 것이 아니라 임금의 사전포기로서 임금 미지급이란 불법의 문제를 낳을 뿐이다. 따라서 통상임금의 개념적 징표의 하나인 고정성의 요건은 통상임금의 본질에 반하고 임금의 사전포기로서 불법의 문제를 낳기 때문에 고정성의 요소는 개념적 징표로서의 역할을 상실하고 있다.

(2) 재직조건의 정기상여금의 통상임금 해당성

재직조건의 정기상여금의 통상임금 해당성 문제는 특정시점에 재직조건을 충족한 근로자에게만 지급하는 정기상여금이 고정성을 결여하여 통상임금에서 배제되어야 하는가의 문제이다. 재직조건부 정기상여금의 통상임금 해당성 문제는 통상임금을 부정하는 견해, 사안에 따라 재직조건의 유효 무효가 달라질 수 있고 그에 따라 통상임금성도 달라질 수 있다는 견해, 재직조건을 무효로 보아 통상임금성을 인정하는 견해로 나뉘어진다.

첫째, 통상임금성을 부정하는 견해는 통상임금에 해당하는 임금의 구체적인 범위는 노사합의나 근로계약을 통하여 정하여 지거나 변경되기 때문에 근로의 대가라는 추상적인 이유로 모든 임금에 대해서 지급일 재직요건과 같은 요건을 요구하는 것을 무효로 볼 수 없기 때문에 재직요건은 유효하고 따라서 통상임금성이 부정된다는 것이다.²⁸⁾

둘째, 절충설은 재직조건을 일률적으로 위법 무효 또는 적법 유효라고 볼 수는 없고 재직조건을 인정해야 할 ‘합리적인 필요성’과 그로 인하여 ‘근로자가 입게되는 손실’의 정도를 비교형량하여 재직조건은 위법 무효일수도 적법 유효일수도 있다는 견해이다.²⁹⁾ 이 견해는 임금항목에 재직자 조건, 일정 근무일수 조건이 있는 경우 퇴직자, 근무일수 미달자에게

28) 임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 서울대학교 노동법연구회, 「노동법연구」 제31호, 2021, 280쪽.

29) 임상민, 앞의 논문, 281쪽.

지급하지 않는 부지급조건은 그러한 부지급조건이 합리적 필요성이 있고 금액비중의 적정성을 갖추어 사회통념상 상당성이 인정되어야 적법하고 유효하다고 한다.³⁰⁾

셋째, 재직조건을 무효로 보아 통상임금성을 인정하는 견해이다. 재직조건은 근로자가 근로제공의 대가로부터 지급받아야 할 임금을 사전에 포기케 하는 약정으로서 근로기준법 제43조 제1항³¹⁾의 임금전액불 원칙, 임금전액지급의 원칙에서 파생하는 임금의 사전포기 금지원칙의 강행규정에 반하고, 나아가 재직조건은 퇴직하려는 근로자로 하여금 정기상여금 지급일까지는 근로를 하게끔 강제함으로서 사실상 근로기준법 제7조가 정하는 강제근로금지의 원칙³²⁾에 반한다.³³⁾

또한 기본임금은 근로계약 등에서 그 지급에 관한 사항을 정하지 않더라도 근로계약 자체의 본질상 근로를 제공하면 당연히 지급하여야 하므로 기본임금 또는 이에 준하는 수당인 정기상여금을 재직에 연동, 결부하여 지급일 당시 재직조건을 충족한 근로자에게만 지급하도록 하고 중도 퇴직자에게는 무조건 지급하지 않기로 하는 약정은 당연히 그 효력이 없는 것으로 보는 것이 근로계약의 본질상 타당하다.³⁴⁾

한편 재직조건을 추가로 규정한 이유가 합리적인 이유없이 특정 임금항목(기본임금, 정기상여금 등)을 통상임금에서 제외시킬 목적으로 이루어진 것이라면 이는 탈법행위로서 무효라고 판단해야 한다는 것이다.³⁵⁾

정기상여금은 그 성격상 기본급과 동일하고(1개월을 초과하여 지급된다는 차이점이 기본급과 다를뿐이다) 소정근로의 대가로 파악하는 것이

30) 김홍영, “통상임금에 포함시키지 않는 재직자조건, 일정근무일수 조건에 대한 비판적 검토”, 서울대 노동법연구회, 『노동법연구』 제37호, 2014, 77쪽.

31) 근로기준법 제43조(임금지급) 제1항은 임금은 통화로 직접 근로자에게 전액을 지급하여야 한다. 고 규정하고 있다.

32) 근로기준법 제7조(강제근로의 금지)는 사용자는 폭행, 협박, 감금 그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로써 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요하지 못한다.라고 규정하고 있다.

33) 임상민, 앞의 논문, 282쪽.

34) 임상민, 앞의 논문, 283쪽.

35) 임상민, 앞의 논문, 283쪽.

합리적이고 당연한 것이다. 그리고 정기상여금에 규정하고 있는 ‘지급일 재직조건’이 지급일 이전에 퇴직한 근로자에게 해당 정기상여금을 무조건 지급하지 않도록 한 의미라면 이는 임금정기지불의 원칙, 임금전액지급의 원칙 및 금품청산의 원칙에 위배되는 것으로서 임금의 사전포기에 해당되어 불법, 무효로 평가될 수밖에 없다. 더불어 재직조건으로부터 임금을 받기 위하여 해당 정기상여금이 지급되는 날까지 부당하게 근로를 강제 받게 됨으로서 근로기준법 제7조의 강제근로금지의 원칙에도 위배된다.

결국 재직조건은 근로기준법이 정한 강행성을 위반하는 것일 뿐만 아니라 공서양속에도 반하므로 무효라고 판단해야 하고 재직조건이 무효인 만큼 해당 정기상여금의 통상임금 해당성은 인정되어야 한다.³⁶⁾

4. 통상임금에 관한 전원합의체 판결(2)의 내용

가. 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결

「고정성 개념은 통상임금의 개념적 징표에서 제외되는 것이 옳다. 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 볼 수 없는 이유는 다음과 같다.

첫째 고정성 개념은 법령상 근거가 없음.

2013년 전원합의체 판결이 말하는 임금의 지급여부나 지급액이 사전에 확정될 것을 의미하는 고정성개념은 법령의 어디에도 근거가 없다. 근로기준법 시행령 제6조 제1항은 통상임금을 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 금액이라고 정의한다. 여기서 ‘지급하기로 정한’이라는 문언은 지급이 미리 정해진 상태, 즉 ‘소정성(所定性)’을 의미한다. 그러한 소정성은 모든 임금에 공통된 징표이지 통상임금에 특유한 개념적 징표라고 볼 수 없다. 이를 2013년 전원합의체 판결이 말하는 ‘고정성’으로 변형하여 해석하고 통상임금의 개념적 징표로 삼은 것은 문언상 근거가 부족하다. 그러한 해석이 입법자의

36) 권오성, “정기상여금에 붙은 지급일 재직조건의 문제점”, 「노동법논총」 제41집, 2017, 248쪽.

의사나 근로기준법의 목적에 부합하는 것도 아니다.

둘째, 통상임금개념의 강행성에 반함.

고정성개념은 통상임금의 강행적 성격과 맞지 않는다. 통상임금은 법정수당 산정의 도구로서 연장근로 등에 대하여 법이 정한 합당한 보상을 하도록 한 강행법규와 관련되어 있다. 따라서 통상임금은 당사자가 그 의미나 범위를 임의로 변경할 수 없는 강행적 개념이다. 2013년 전원합의체 판결은 자율의 영역에 속하는 ‘조건’을 후견의 영역에 속하는 ‘통상임금’과 부당하게 결부시킨 근본적인 문제가 있다. 2013년 전원합의체 판결은 근로관계 당사자가 어떤 임금 항목에 조건을 부가하여 그 지급여부와 지급액이 사전에 확정될 수 없는 경우 고정성이 결여되어 통상임금이 아니라는 법리를 제시하였다. 이로써 당사자가 강행적 성격을 가지는 통상임금의 범위를 쉽게 좌우할 수 있게 허용하는 결과가 발생하였다. 사용자가 종속노동관계 하의 근로관계에서 우월적 지위로부터 임금에 특정한 조건을 덧붙임으로써 통상임금의 범위를 부당하게 축소할 위험도 초래하였다.

예를들어 운수회사에서 일정기간동안 교통사고가 발생하지 않을 것을 조건으로 지급하는 무사고수당은 무사고라는 조건의 성취여부가 불확실하기 때문이 아니라 소정근로제공 외에 무사고라는 추가적인 자격요건 달성에 대한 보상으로서 지급되는 것이어서 소정근로 대가성이 결여되어 통상임금성이 부정되는 것이다.

셋째, 소정근로의 가치를 온전하게 반영하지 못함.

통상임금은 소정근로의 가치를 평가한 개념이므로 실제의 근로제공과 무관하게 소정근로 그 자체의 가치를 온전하게 반영하는 것이라야 한다. 이점에서 통상임금은 근로자에게 실제 지급된 임금의 총액을 기초로 하여 사후적으로 산정되는 평균임금과 구별된다.

2013년 전원합의체 판결이 고정성을 갖춘 임금을 근로자가 일정한 날에 소정근로를 제공하면 업적, 성과 등의 추가적인 조건의 충족여부와 관계없이 당연히 지급될 것이 예정된 임금이라고 정의하여 조건충족 여부에 임금지급여부가 연계되면 고정성이 결여된다고 본 것은 실제의 임금

의 변동 가능성이 통상임금에 투영되는 것을 통해 통상임금의 본질을 지켜내려는 기능에 부합하지 않는다.

즉, 만약 그 조건이 ‘실제 근무일수’처럼 소정근로가 아닌 실근로와 관련된 것이라면 실제의 근로제공이란 사후적 성격의 임금이 통상임금에 영향을 미치고 이러한 조건을 통로삼아 실근로에 관한 요소가 통상임금 개념에 영향을 미치게 되어, 통상임금의 본질에 반한다.

넷째, 통상임금의 사전적 산정가능성을 약화시킴.

통상임금은 연장근로 등을 제공하기 전에 산정될 수 있어야 한다. 그래야 사용자와 근로자는 연장근로에 대한 비용의 정도를 예측하여 연장근로를 할지 안할지 한다면 어느 정도를 할지에 관한 합리적 의사결정을 할 수 있고 연장근로가 실제 제공된 때에 가산임금을 곧바로 산정할 수 있다. 2013년 전원합의체 판결은 사전적으로 정해져야 할 통상임금 여부를 임금의 지급여부나 지급액의 확정여부에 따라 결정하려고 하였다는 문제가 있다.

다섯째, 연장근로 등의 억제라는 정책목적에 부합하지 않음.

통상임금 개념은 연장근로 등의 억제라는 근로기준법의 정책목적에 부합하여야 한다. 연장근로 등은 근로자에게 상당한 피로와 긴장을 주고 근로자가 향유할 수 있는 자유시간을 제한하므로 근로기준법은 연장근로를 일정시간 금지하는 규정을 두면서(근로기준법 제53조) 연장근로에 대해 가산임금을 지급하도록 하는 한편(근로기준법 제56조) 연장근로 등 관련 규정 위반에 관한 처벌규정도 두고 있다.(근로기준법 제109조, 제110조) 이는 근로자의 적정하고도 인간다운 생활을 보장하기 위하여 연장근로를 억제하고 연장근로의 가치에 상응하는 보상을 해주려는데 그 목적이 있다. 그런데 고정성 개념은 통상임금의 범위를 법령상 근거없이 축소시킴으로서 연장근로를 억제하고 연장근로에 상응하는 보상을 하려는 근로기준법의 정책목적에 부합하지 않는 결과를 발생시켰다.」

나. 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결

「법령의 정의와 취지에 충실하게 통상임금 개념을 해석하면 통상임금은 소정근로의 대가로서 정기적 일률적으로 지급하기로 정한 임금을 말한다. 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가되고 덧붙여진 조건의 존재 여부나 달성여부에 관계없이 통상임금에 해당한다. 어떤 임금에 일정 근무일수를 충족하여야만 지급한다는 조건(근무일수 조건)이 부과되어 있더라도, 정해진 근무일수 조건인 경우에는 그러한 조건이 부가되고 덧붙여졌다는 사정만으로 그 임금의 통상임금성이 부정되지 않는다. 설령 실제 근무일수가 소정근로일수에 달하지 못하여 근로자가 근로일수 조건의 임금을 지급받지 못하더라도 그 임금이 소정근로 대가성, 정기성, 일률성을 갖추고 있는 한 이를 통상임금에 산입하여야 한다. 통상임금은 실제의 근로를 제공한 실제의 근로일수에 관계되지 않고 소정근로의 가치를 온전하게 반영하여 정한 기준임금이기 때문이다.

반면 소정근로일수를 초과하는 근무일수 조건부 임금은 소정근로를 제공하였다고 하여 지급되는 것이 아니고 소정근로를 넘는 추가근로의 대가이므로 통상임금이 아니다.」

다. 검토

첫째, 고정성개념은 법령상 근거가 없다. 근로기준법에는 통상임금에 관한 정의규정이 없고 근로기준법 시행령 제6조 제1항에서 통상임금이란 근로자에게 정기적 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 금액이라고 정의하고 있을 뿐이다. 고정성이란 개념 징표는 법령상 근거가 없는 것으로서 통상임금의 범위를 근거없이 축소시키고 있다.³⁷⁾

판례는 재직조건이나 근무일수 조건의 정기상여금에서 재직조건이나

37) 이새롭, “통상임금의 개념 및 판단기준: 고정성 폐기를 통한 통상임금 범리의 변경”, 사법발전재단, 「사법」 제1권 제72호, 2025, 616쪽.

근무일수 조건을 충족하지 않으면 정기상여금을 배제하여 고정성을 결여한 것으로 평가, 통상임금의 범위에서 제외되는 것으로 판단하였다. 그러나 고정성이란 요건은 아무런 법적 근거없이 통상임금의 개념적 징표가 되어, 사용자가 임의적으로 재직조건이나 근무일수 조건을 정기상여금의 지급근거로 내세워 통상임금이 사용자의 자의에 의해 축소되는 결과가 되었다.

둘째, 고정성은 통상임금 개념의 강행성에 반한다. 2013년 대법원 전원합의체 판결은 일정한 특정 임금항목에 조건을 붙여서 그 지급여부가 확정될 수 없는 경우 고정성을 부정하여 통상임금이 아니라는 태도를 취하였다. 이 판결의 근본적인 문제는 자율의 영역에 속하는 ‘조건’의 문제를 후견의 영역에 속하는 통상임금과 부당하게 결부시켜서 당사자가 어떤 임금에 재직조건이나 근무일수 조건을 부가하여 쉽게 그 임금을 통상임금에서 배제될 수 있도록 허용함으로써 통상임금의 강행성을 잠탈할 위험을 초래하였다는 것이다.³⁸⁾ 그리고 사용자가 종속노동관계 하에서 우월적 지위에서 임금에 조건을 부가하여 통상임금의 범위를 부당하게 축소시키는 문제도 확대되었다.

셋째, 고정성은 소정근로의 가치를 온전하게 반영하지 못하는 문제를 가진다. 2013년의 대법원의 전원합의체 판결은 고정성을 갖춘 임금인가의 문제에서 근로자가 일정한 날에 소정근로를 제공하면 업적, 성과 등의 추가적인 조건의 충족여부와 관계없이 당연히 지급될 것이 예정된 임금이라고 정의하여 조건충족여부와 임금지급 여부를 연계시켜 고정성이 결여된다고 판단하였다. 그러나 통상임금은 가상의 추상적인 도구개념이고 그 개념이 전제하는 것은 소정근로제공을 온전하고 적절히 제공하는 근로자이어야 하고 소정근로의 온전한 제공이라는 요건이 충족되기만 하면 바로 이를 이유로 지급되는 것이 가상의, 추상적인 임금으로서 통상임금인 것이다.³⁹⁾

38) 이새롭, 앞의 논문, 617쪽.

39) 이새롭, 앞의 논문, 618-619쪽.

만약 일정한 조건을 통로삼아 실근로에 관한 요소가 통상임금 개념에 영향을 미치게 된다면 이는 소정근로의 가치를 온전하게 반영해야 하는 통상임금 개념요청을 위태롭게 하는 것이다.⁴⁰⁾ 재직조건이나 근무일수 조건을 통해 재직조건이나 근무일수 조건을 충족하고 있는가를 판단하고 실제의 근무제공일수가 부족한 경우 해당 상여금이 지급되지 않도록 하여 고정성을 결여했다고 판단, 통상임금 해당성을 부정하는 것은 결국 실제근로제공일수가 상여금지급에 영향을 미치는 것이고 그것은 사전적 소정근로의 가치인 통상임금의 본질에 반한다. 결국 2013년 대법원 전원합의체 판결은 조건충족 여부를 통해 실근로의 결과가 상여금의 지급에 영향을 미쳐서 통상임금의 본질적 도구로서의 기능을 상실하도록 하였다는 것이다.

넷째, 고정성의 요소는 통상임금의 사전적 산정가능성을 약화시킨다. 조건을 통하여 사후적으로 변동가능성이 있고 달라질 수 있는 ‘실제근로’를 ‘통상임금’과 연동, 연계하게 되면 통상임금의 사전적 산정가능성이 약화된다. 통상임금의 사전적 산정가능성은 실제의 근로가 아니라 미리 정해진 소정근로와 연동, 연계될 때만이 적절하게 확보될 수 있다. 통상임금은 연장근로를 제공하기 전에 산정될 수 있어야 하고 그래야 연장근로에 대한 비용을 예측하여 연장근로에 관한 의사결정을 적절하게 할 수 있다. 고정성의 요소는 통상임금이 소정근로제공에 대한 대상성으로서 사전적 가치로서의 본질을 약화시킨다.

다섯째, 고정성은 연장근로 등을 억제하는 정책적 목표에 부합하지 않는다. 연장근로 등은 근로제공을 하는 근로자에게 상당한 피로와 긴장을 주고 근로자가 향유할 수 있는 자유시간을 제한한다. 이에 따라 근로기준법은 연장근로에 대한 제한 규정을 두고 있고(1주 12시간 이내의 한도에서 연장근로 할 수 있음) (근로기준법 제53조) 연장근로에 등에 대해 가산한 임금을 지급(근로기준법 제56조)하도록 하고 있으며 이러한 연장근로 관련 규정 위반에 대한 처벌조항을 두고 있다.(근로기준법 제109조, 제

40) 이새롭, 앞의 논문, 619쪽.

110조) 통상임금을 기초로 하여 연장수당, 야간수당, 휴일근로수당을 산정하는 만큼 통상임금의 개념은 가급적 연장근로 등을 억제하기 위한 이념에 부합하여야 한다. 고정성 요소는 통상임금의 범위를 법령상 근거없이 혹은 사용자의 자의에 의하여 부당하게 축소함으로써 연장근로 등에 대한 억제이념에 부합하지 않는다.

2020다247190 판결은 재직조건부 상여금의 통상임금성 판단부분에서 「이 사건 상여금은 재직조건에도 불구하고 소정근로의 대가로서 정기적 일률적으로 지급하는 통상임금에 해당한다. 원심이 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 보아 이를 전제로 판단한 부분은 잘못이나 이 사건 상여금을 통상임금으로 인정한 원심의 결론은 정당하다.」고 판시했고 여기서 재직조건이 효력이 직접적으로 판단되지는 않았다.⁴¹⁾

2023다302838 판결은 「원심이 이 사건 상여금은 일정한 근무일수 조건을 성취하여야 지급되는데 근로제공 시점에 그 조건의 성취가 불확실하여 고정성이 없다는 등의 이유로 이 사건 상여금은 통상임금이 아니라고 판단하였다. 그러나 근무일수 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 이 사건 상여금의 통상임금성이 부정된다고 볼 수 없다. 이 사건 상여금은 통상임금의 750%에 해당하는 일정한 금액을 일정한 주기로 분할하여 지급하는 임금이므로 근무일수 조건에도 불구하고 소정근로의 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 통상임금에 해당한다.」고 판단했다.

IV. 통상임금의 개념에 관한 향후의 과제

1. 임금의 법적성질과 통상임금

통상임금에 해당하느냐 아니냐의 문제는 임금의 개념이나 범위의 문제

41) 정현주, 「재직조건부 상여금의 통상임금 인정. 그 의의와 남은 과제」, 한국노동법학회, 「노동법학」 제93호, 2025, 411쪽.

와 긴밀하게 연결되어 있다.

임금의 발생근거에 관한 임금의 본질론에는 세 가지의 학설이 있다.

첫째는 노동대가설이다. 노동대가설은 근로계약을 근로와 임금의 교환 계약으로 보고 근로제공의 대가로 임금의 지급이 행해진다고 파악한다.⁴²⁾ 즉, 현실적이고 구체적인 노동제공에 대한 대가를 임금으로 보는 것이다. 둘째, 노동력대가설인데, 임금을 구체적 근로에 대한 대가로 보지 않고 근로자 자신의 노동력을 일정시간 사용자의 지휘, 명령하에 즉 처분하에 맡기는 것에 대한 대가로 보는 견해이다.⁴³⁾ 이 입장은 근로계약의 구조도 구체적 근로제공 그 자체의 제공을 약속한 것이 아니라 일정한 조건하에 노동력의 처분권을 사용자에게 주는 계약으로 보는 것이 타당하다고 한다.⁴⁴⁾ 셋째, 임금이분설로 근로계약의 이중구조의 분석으로부터 임금청구권을 설명한다. 임금에는 두 가지 부분, 즉 구체적 근로와 직접 결부되어 있는 부분(교환적 임금)과 그렇지 않은 부분(보장적 임금)으로 구분된다고 한다.

보장적 임금은 종업원이라고 하는 지위에 대하여 지급되는 것으로서 종업원에 대한 생활보장의 의미가 포함된 것으로서 대체로 가족수당, 통근수당, 별거수당, 물가수당 등의 임금이 여기에 해당하고, 교환적 임금은 근로자가 그의 노동력을 사용자의 처분에 맡기고 그 상태를 일정시간 유지하는 것에 대응한 것에 따라 지급되는 것으로 파악하여 대체로 정근수당, 근무성적급, 직무급, 직능급, 특수직무수당 등이 해당한다고 한다.⁴⁵⁾

판례는 과거에 임금이분설의 입장을 취하였으나 전원합의체 판결을 통해 임금일체설로 변화하였다. 즉 「모든 임금은 근로의 대가로서 근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수를 의미하므로 현실의 구체적 근로제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자로서의 지위 즉 근로자의 생활을 보장하기 위한 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수

42) 김유성/이홍재, 「노동법 I」, 한국방송통신대학교, 1993, 187쪽.

43) 김유성/이홍재, 앞의 책, 187쪽.

44) 김유성/이홍재, 앞의 책, 188쪽.

45) 김유성/이홍재, 앞의 책, 188쪽.

없고 또한 우리 현행법상 임금을 원심과 같이 사실상 구체적 근로를 제공한데 대하여 지급받는 교환적 부분과 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 이분할 아무런 법적 근거도 없다.」⁴⁶⁾고 한다.

이에 따라 임금이분설의 입장 하에서 구체적 근로제공에 근거한 교환적 부분만이 통상임금에 해당한다는 판단은 그 기능을 상실했다고 평가하는 입장도 있다.⁴⁷⁾

그러나 첫째, 근로기준법상 근로자의 생존을 배려하기 위해 일정한 사회법적 보호와 규제를 가하면서 퇴직금, 휴업수당, 유급휴일수당, 연차휴가수당 등을 보장하고 있는 것을 고려한다면 현실적으로 근로를 제공하지 않고 받는 임금의 존재를 일률적 전면적으로 부정할 수는 없다.⁴⁸⁾ 둘째, 판례처럼 임금이분설의 부정이란 전제하에 현실적 노무제공과 직접 관계되지 않은 모든 임금을 부정하는 논리로 나아간다면 이런 논리는 근로기준법의 사회법적 기능을 망각하는 것으로 될 것이다.⁴⁹⁾ 셋째, 근로기준법 시행령 제6조 제1항의 통상임금 개념을 살펴보더라도 보장적 임금의 존재를 예정 인정하고 있다고 평가할 수 있고⁵⁰⁾ 현실적으로 판례도 보장적 부분의 임금을 가족수당의 경우와 같이 인정하고 있다고 평가되기 때문에 모든 임금은 교환적 부분의 임금과 보장적 부분의 임금으로 나뉘어 진다고 생각한다. 판례는 부양가족이 있는 근로자에게만 지급되는 가족수당의 경우 이는 소정근로의 가치평가와 관계없는 임금이라고 하여 실질적으로 보장적부분의 임금을 인정하고 있는 것으로 보여진다.

즉, 「부양가족이 있는 근로자에게만 지급되는 가족수당과 같이 소정근로의 가치평가와 무관한 사항을 조건으로 하여 지급되는 임금은 통상임금에 속한다고 볼 수 없다. 그러나 모든, 전체의 근로자에게 기본금액을

46) 대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 판결.

47) 이승길, “상여금의 통상임금에 관한 판례법리의 소고”, 「가천법학」 제5권 제2호, 2012, 279쪽.

48) 유혜경, 앞의 책, 427쪽.

49) 유혜경, 앞의 책, 427쪽.

50) 김유성/이홍재, 앞의책, 189쪽.

가족수당 명목으로 지급하면서 실제 부양가족이 있는 근로자에게는 일정액을 추가적으로 지급하는 경우 모든 전체근로자에게 지급되는 그 기본금액은 소정근로에 대한 대가에 다름 아니므로 통상임금에 속한다.⁵¹⁾라고 하였다.

보장적 부분의 임금이 현실적으로 존재한다면 모든 임금은 교환적 부분의 임금과 보장적 부분의 임금으로 나누어진다. 교환적 부분의 임금이란 근로의 제공을 대상으로 한 교환적 가치의 임금으로서 기본급과 같이 원칙적으로 통상임금에 해당하고 보장적 부분의 임금은 근로기준법 시행령 제6조 제1항의 정기적 일률적인 임금이 통상임금에 해당한다. 즉, 보장적 부분은 근로자의 생활을 보호하기 위해 지급되는 임금으로서 정기성과 일률성을 갖추면 통상임금이 되는 것이다. 근로자의 생활을 보장하기 위해 구체적 근로제공과 직접 관계되지 않고 보장되는 보장적 임금도 그것이 정기적이고 일률적으로 지급되면 기본급과 같이 변화되어 통상임금에 해당한다.

결론적으로 통상임금이란 <기본급 + 정기적 일률적 수당>으로서 기본적으로 근로의 대가를 기초로 한 교환가치로서의 기본급과 보장적 부분의 임금으로서 정기성과 일률성을 갖추면 통상임금에 해당한다.

2. 일본의 통상임금의 구조

일본은 할증임금의 산정기초에서 제외되는 임금을 노동기준법 규칙에 규정하는 방식으로 하여 통상의 노동시간의 임금의 산정을 규율하고 있다.⁵²⁾ 그 내용은 다음과 같다. 노동기준법 (제37조 제5항) 및 노동기준법 시행규칙 (제21조)에 따라 할증임금의 산정기초에서 제외되는 임금의 종류는 세 가지로 ① 가족수당, 통근수당, 별거수당, 자녀교육수당, 주택수당 ② 임시로 지급된 임금 ③ 1개월을 초과하는 기간마다 지급된 임금이다.⁵³⁾

51) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

52) 이 정, “통상임금에 대한 판례법리의 재검토”, 한국노동법학회, 「노동법학」 제43호, 2012, 204쪽.

상여금의 통상임금여부에 대한 일본의 판단기준은 의외로 간단한데 우리나라와 같이 정기성, 일률성, 고정성이라는 복잡한 개념요소를 내세우지 않고 해당 상여금을 할증임금의 산정기초가 되는 임금으로 보는 것이 적합한가라는 관점에서 판단할 뿐이다.⁵⁴⁾ 즉 해당 상여금의 지급시기, 지급액 등이 미리 확정되어 있다면 할증임금의 산정기초로 보고 반대로 해당 상여금이 임시적인 것이라면 계산 기술상의 문제가 있으므로 ‘통상 근로시간의 임금’으로 보지 않는다.⁵⁵⁾

우리나라 근로기준법 시행령 제2조(평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금) 제2항이 시사하는 바처럼 “제2항 법 제2조 제1항 6호에 따른 임금의 총액을 계산할 때는 임시로 지급되는 임금 및 수당과 통화외의 것으로 지급된 임금은 포함하지 아니한다”라는 규정처럼 통상임금에서 제외되는 임금(임시로 지급되는 임금과 수당 등)을 시행령에서 규정하는 방법도 한 방법일 수 있다고 생각한다.

V. 결론

통상임금이란 통상이라는 사전적 의미처럼 특별하지 않는 늘, 항상있는 일로서 통상의 근로에 대한 대가이다. 통상임금은 소정의 근로시간에 대한 소정의 정해진 업무를 한 것에 대한 대가이다. 따라서 소정 근로시간 내의 업무라도 사전에 정해진 업무가 아닌 특별한 예외적인 업무에 대한 대가는 통상임금이 아니며 소정 근로시간의 소정업무에 대한 일반적인 근로의 대가가 아닌 특별한, 예외적인 대가는 통상임금에 해당하지 않는다.

통상임금의 해당성에 관한 판례에서 첫째, 상여금의 통상임금 해당성

53) 이 정, 앞의 논문, 204쪽.

54) 이 정, 앞의 논문, 206쪽.

55) 이 정, 앞의 논문, 206쪽.

을 부정한 판례에서는 상여금이 근로제공을 한 근무일 수 만큼 일할 계산되어 결근한 만큼 상여금이 삭감되어 해당 상여금은 근무성적에 따라 지급되므로 통상임금에서 제외된다고 하였다.

즉 근무일수를 근거로 일할 계산 → 근무성적에 따라 좌우되는 임금 → 비교정적 임금 → 통상임금에서 제외됨 이었다.(대법원 1996. 2. 9. 선고 94다19501 판결)

둘째, 상여금의 통상임금 해당성을 긍정한 판례는 상여금이 퇴직자에 대하여 월별로 계산 지급된다는 규정을 기본급과 동일하게 판단함으로써 당해 상여금이 근무성적에 따라 좌우되는 임금인가의 문제에서 실질성을 확보해서 임금공제의 문제와 근무성적에 따른 임금인가의 문제를 구별하였고 그런 만큼 ‘고정성’의 요건을 완화하여 통상임금의 범위를 확대하였다.(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91406판결: 금아 리무진 사건)

셋째, 2013 전원합의체 판결에서는 통상임금의 개념적 징표를 정기성, 일률성, 고정성이라고 평가하여 통상임금의 해당 여부를 판단했다. 그러나 고정성의 요건이 근로기준법 시행령 제6조의 제1항의 규정요소가 아니라는 점에서 문제되었고, 재직 조건의 정기상여금의 통상임금 해당성 판단에서 재직조건으로 정기상여금을 지급한다는 것은 재직하지 않는다면 근로제공을 한 경우에도 정기상여금을 지급받을 수 없어서 결국 고정성이 결여되어 통상임금에서 제외된다는 결론이 나오게 되었다. 이는 고정성의 여부의 문제이기 보다 근로제공을 한 근로자의 임금의 사전포기(임금 미지급)의 불법의 문제를 일으켰다. 근로제공을 한 근로자에게 재직요건을 이유로 재직하지 않으면 정기상여금을 지급하지 않는다는 것은 임금전액불 원칙, 임금 정지지불의 원칙, 강제근로 금지의 원칙을 위배하는 것으로서 근로기준법의 강행성에 반하는 불법의 문제를 일으키는 것이다.

넷째, 2024년 전원합의체 판결에서는 통상임금의 개념에서 고정성의 요건을 폐기하여 통상임금의 범위를 확대하였다. 즉 고정성의 요건은 법령상 근거가 없다는 것, 통상임금개념의 강행성에 반한다는 것, 소정근로

의 가치를 온전하게 반영하지 못한다는 것, 통상임금의 사전적 산정가능성을 약화시키는 것, 연장근로 등의 억제라는 정책목표에 부합하지 않는다는 것을 이유로 폐기되었다.

통상임금은 임금의 법적 성질과 연결되어 통상임금의 해당성 여부가 판단되어야 한다. 그러할 때 현실적으로 보장적 부분의 임금을 인정해야만 한다. 근로기준법상 퇴직금, 휴업수당, 유급휴일수당, 연차휴가수당 등은 구체적 근로제공 없이 지급되는 임금으로 구체적 근로제공 없이 지급되는 임금을 전면 부정할 수 없고 근로기준법이 근로자의 생활을 보호하기 위해 여러 가지 보호정책으로 근로자를 보호하고 있는 것을 고려한다면 현실적 노무제공과 직접 관계되지 않는 모든 임금을 부정하는 것은 근로기준법의 사회법적 기능을 망각하는 것으로 될 것이다. 그리고 부양가족이 있는 근로자에게만 지급하는 가족수당의 경우 구체적 근로제공과 관계없이 지급하는 임금으로 보장적 부분의 임금이 현실적으로 존재한다는 것을 확인해 준다.

그렇다면 모든 임금은 구체적 근로제공과 관계된 교환적 임금과 근로자의 생활을 보호하기 위한 보장적 임금으로 이분되고 결국 첫째 통상임금은 소정근로의 대상으로서 교환적 임금으로 구성되고 둘째, 보장적 부분의 임금 중 정기성 일률성을 충족하는 임금부분으로 구성된다.

보장적 부분의 임금이 구체적 근로제공과 직접 관계되지 않고 근로자의 생활을 보장하기 위해 지급되더라도 보장적 임금이 정기성과 일률성을 갖추면 그 보장적 임금은 기본급과 같이 변화되어 통상임금에 해당한다. 즉, 근로자의 생활을 보호하기 위해 지급되는 보장적 임금이라도 그 보장적 부분이 일시적인 것이 아닌 정기적, 일률적으로 지급되면, 그 보장적 부분은 해당 근로자의 노동력의 가치로 양질전화되어 기본급과 같이 됨으로써 통상임금이 되는 것이다.

참고문헌

- 권오성, “정기상여금에 붙은 지급일 재직조건의 문제점”, 『노동법논총』 제 41집, 2017.
- 김유성/이홍재, 『노동법 I』, 한국방송통신대학교, 1993.
- 김유성, 『노동법 I』, 법문사, 2005.
- 김성진, “통상성으로 본 대법원의 통상임금법리”, 한국노동법학회, 『노동법학』 제49호, 2014.
- 김소영, “판례법리에 의한 통상임금 판단기준의 경향과 변화”, 한국비교노동법학회, 『노동법논총』 제25집, 2012.
- 김홍영, “통상임금에 포함시키지 않는 재직자조건, 일정근무일수 조건에 대한 비판적 검토”, 서울대 노동법연구회, 『노동법연구』 제37호, 2014.
- 박수근, “통상임금의 실태와 본질에 관한 검토”, 『인권과 정의』 443, 2014.
- 유혜경, 『노동법』, 기저출판, 2015.
- 임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 서울대학교 노동법연구회, 『노동법연구』 제31호, 2021.
- 이새롬, “통상임금의 개념 및 판단기준: 고정성 폐기를 통한 통상임금 법리의 변경”, 사법발전재단, 『사법』 제1권 제72호, 2025.
- 이승길, “상여금의 통상임금에 관한 판례법리의 소고”, 『가천법학』 제5권 제2호, 2012.
- 이 정, “통상임금에 대한 판례법리의 재검토”, 한국노동법학회, 『노동법학』 제43호, 2012.
- 이철수, “통상임금의 법리”, 서울대학교 노동법연구회, 『노동법연구』 제3호, 1993.
- 정현주, “재직조건부 상여금의 통상임금 인정. 그 의의와 남은 과제”, 한국노동법학회, 『노동법학』 제93호, 2025.

<Abstract>

Changes in Court Precedents on Ordinary Wages and Future Challenges of Ordinary Wage

Yu, Hea-Kyung^{*}

In determining whether a certain wage falls under the category of ordinary wage, it is important to consider the legal nature of the wage. In reality, there exist protective wages, such as family allowances, which are intended to guarantee workers' livelihoods. The grounds for the existence of such protective wages are as follows.

First, just as the Labor Standards Act guarantees retirement pay, suspension allowances, and paid holiday allowances, it is not possible to categorically deny the existence of wages paid without the actual provision of labor. Second, the logic of denying all wages that are not directly related to the actual provision of labor leads to neglecting the social-law function of the Labor Standards Act.

Accordingly, wages are divided into exchange-based wages and protective wages. Ultimately, under the dual wage theory, ordinary wage is composed as follows.

First, ordinary wage consists of exchange-based wages that are based on the provision of labor. Second, if protective wages meet the requirements of regularity and uniformity, they are transformed into ordinary wages just like base pay.

Key Words: ordinary wage, regular and uniform wage, exchange-based wage, protective wage, legal nature of wage

^{*} Ph.D., Kyunghee University College Of Law